

1500945-06.2021.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... há anotação de condenação definitiva por tráfico de 2014, três furtos de 2012, 2013 e 2014, um falso testemunho em 2014, além de um furto posterior a este processo (fl. 165).

As condenações já depuradas pela reincidência devem valer como antecedentes criminais ao menos por mais 5 anos após a depuração da reincidência ou pelo prazo prescricional aplicável.

Assim, utilizarei as 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500945-06.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500945-06.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2086719/2021 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 11817599 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 1132/20/114 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2086719 - DEL.INV.GER. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DENIS HALLAN DE SOUZA e outro

O Ministério Público ofereceu denúncia contra DENIS HALLAN DE SOUZA imputando-lhe a prática do crime de furto simples (Art. 155 § 1º do CP, por três vezes).

Narra a denúncia que no dia 09 de dezembro de 2020, por volta da 01h30min, na Rua Marechal Deodoro, nº 861, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado à fls.86/89 e 147 dos presentes autos, subtraiu para si, 03 aparelhos de telefonia celular, sendo um "Samsung", um "LG" e outro "Positivo", avaliados em R\$ 2.385,30 (cf. auto de fls.128/131), pertencentes, respectivamente, a Luiz Vicente Palmeira da Silva e Werbetty Silva de Sales e Geison Souza Lins.

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 em decisão de fls.199/200. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls. 213/218.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, deixou de requerer a absolvição em razão da confissão do acusado, fazendo pedidos subsidiários em relação à sanção penal a ser aplicada.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (Inquérito policial de fl.01, boletim de ocorrência de fls.04/06, 63/65, 69/70, 111/115, termo de declarações de fls.22/24, 56/57, 60/62, 66/68, 89/99 e 140, autos de exibição e apreensão de fls.58/59, fotografias de fls.102/109.), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido: Geison Souza Lins, vítima, contou que estavam dormindo no momento do furto, sendo que, além de sua pessoa, também Luiz Vicente e Werberty foram furtados. Disse que acordaram e perceberam que sumiram os três telefones celulares, sendo que apenas Vicente recuperou o bem.

Alessandro José Pereira, testemunha e policial civil, afirmou que as três vítimas lavraram BO indicando que uma pessoa invadiu o imóvel de madrugada e furtou 3 celulares. Conseguiram chegar ao acusado, que acabou confessar os fatos. O réu falou que trocou esses aparelhos por crack e se disse arrependido. Conseguiram recuperar um dos aparelhos celulares, que foi apreendido e devolvido para a vítima. Os outros aparelhos não foram localizados.

A testemunha e policial civil, Everton de Abreu Feitosa confirmou a versão de seu colega, apresentando detalhes de como as investigações se desenrolaram.

Interrogado, o réu confirmou integralmente os fatos, dizendo que realmente invadiu a residência onde as vítimas dormiam e subtraiu os três aparelhos celulares.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto simples é procedente.

A vítima Geison foi ouvida em juízo e confirmou que os três aparelhos foram furtados enquanto dormia juntamente com as outras vítimas, sendo que apenas o telefone celular de Luiz Vicente foi recuperado.

Os policiais civis confirmaram os fatos, detalhando o desenrolar das investigações e a forma pela qual chegaram ao acusado Denis Hallan como autor dos fatos, o qual estava preso em Pereira Barreto e, interrogado, confessou a subtração dos aparelhos.

Quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se (AgRg no HC 583297 / SC): "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Cabe, ainda, reconhecimento da majorante da prática do crime durante o repouso noturno. Anoto que para a configuração da referida majorante, prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na

empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018).

Ainda que o crime tenha sido praticado na modalidade simples a majorante é aplicável, afastando-se a aplicação topográfica, pois ao furto qualificado, previsto no § 4º, se reconhece a possibilidade de aplicação do privilégio, previsto no § 2º. A mesma lógica deve ser aplicada ao furto simples (aplicação do parágrafo § 1º ao caput).

No mais, não basta a simples alegação de necessidade de tratamento para que haja o reconhecimento de inimizabilidade penal, o qual é pressuposto para aplicação de qualquer medida de "tratamento". No mais, certo que o réu demonstrou ter consciência sobre os fatos, tratando-se de embriaguez prévia e voluntária, a qual não induz ausência de culpabilidade. Anoto que, instada em audiência, a defesa não requereu qualquer medida para apurar eventual inimizabilidade do acusado.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso

assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, a pena-base deve ser exasperada, em razão dos antecedentes criminais do acusado. Observo de sua Folha de Antecedentes (fls. 153/190) que o réu ostenta ao menos 10 execuções criminais (2 de tratamento ambulatoria, 3 cumpridas e 5 por cumprir), sendo que na certidão de fls. 153/166 há anotação de condenação definitiva por tráfico de 2014, três furtos de 2012, 2013 e 2014, um falso testemunho em 2014, além de um furto posterior a este processo (fl. 165).

As condenações já depuradas pela reincidência devem valer como antecedentes criminais ao menos por mais 5 anos após a depuração da reincidência ou pelo prazo prescricional aplicável.

Assim, utilizarei as 4 condenações (3 cumpridas e 1 por cumprir) a título de antecedente criminal na primeira fase, e as demais (4 por cumprir) como reincidência, na segunda fase. Por serem vários os antecedentes, a pena-base será exasperada em 1/6, e não 1/8.

Ressalto que a pena partirá do mínimo legal (1 ano) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 2 ANOS e 6 MESES e NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de

mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (1 ano) o montante de 6 meses de reclusão, montante equivalente a 1/6 de 3 anos (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 68 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado ostenta múltipla reincidência (4 condenações a serem valoradas nesta fase), o que por questões de isonomia demandaria agravamento da pena em patamar superior a 1/6. Entretanto, confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ, a qual considera ser inviável a "compensação" integral no caso de múltipla reincidência (REsp 1360952/DF, 6ª Turma, Julgado em 09/12/2014 e HC 280498/SP, 5ª Turma, Julgado em 02/12/2014), duas das condenações será desprezada, neutralizando-se com a confissão.

As outras demandam o agravamento da pena em também 1/6, pelo mesmo critério, chegando-se a 2 anos de reclusão e 126 dias-multa.

Na terceira fase, diante da majorante prevista no art. 155, § 1º, aumento a pena em 1/3, levando a reprimenda a 2 anos e 8 meses de reclusão e 168 dias-multa.

Por fim, observo que deve ser considerado o concurso formal de crimes, em razão do crime ter sido praticado no mesmo contexto, e porque a jurisprudência possui entendimento de que nestes casos não se aplica o cúmulo material, inclusive por razões de proporcionalidade. Por serem 3 os fatos, cabe novo aumento em 1/5 (desta vez calculado a partir da pena anterior), chegando a reprimenda final em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 201 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, quantidade de pena e multirreincidência, deve ser o fechado.

Diante de tal parâmetro, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO DENIS HALLAN DE SOUZA, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, § 1º, do Código Penal, por três vezes em concurso formal, à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 201 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, a qual fica aqui deferida por conta das condições econômicas do acusado.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Corrija-se o cadastro do réu em sistema, que consta em duplicidade.

Andradina, 24 de maio de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)